

1500151-56.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... vara da infância e juventude por tráfico. Ficou 03 anos em Campinas e não se envolveu com o tráfico. Estava trabalhando com jardinagem. É seu primeiro processo depois dos 18 anos. É usuário de maconha e faz uso a noite. Nunca ficou internado. O pé de maconha era para seu consumo. De outro lado, o Guarda Civil Municipal Sergio Henrique Carriel, ouvido em sede policial (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500151-56.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026519/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 22714276 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 228/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2026519 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

KAUAN GABRIEL DIAS MARCELO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" § 1º, II do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a)

CP(Denúncia)

Data da Audiência:

25/04/2022

Réu Preso

Em 25 de abril de 2022, às 16:00h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu KAUAN GABRIEL DIAS MARCELO, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Antonio Rezende Fogaca de Almeida OAB 61484/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas WILIAN SAMUEL DO AMARAL, Sergio Henrique Carriel (GM) e Geraldo Coelho (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal

de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu KAUAN GABRIEL DIAS MARCELO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processo como incurso no art. 33, caput, e § 2º, inciso II, ambos da Lei 11.343/06, eis que, no dia 26 de janeiro de 2022, por volta das 19h50, na Rua João Abrame, nº 70 - Jardim Santa Rita de Cássia, nesta cidade e Comarca de Tatui, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 17 porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 27 gramas, 4 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 2 gramas, e 1 vaso contendo 1 muda de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", planta que se constitui em matéria-prima para a preparação de drogas, bem com o entregou 1 porção de cocaína, com peso bruto aproximado de 0,5 grama, para Wilian Samuel do Amaral, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, o acusado se dedicava ao tráfico ilícito de drogas e, para tanto, permanecia em frente à sua residência, local que elegeu como "ponto", aguardando usuários para promover a venda oportuna. Guardas Cíveis Municipais estavam em serviço quando receberam informação dando conta de que o denunciado estava vendendo drogas em frente à sua residência, localizada na Rua Rua João Abrame, nº 70 e, de imediato, deslocaram-se para o endereço informado. Assim é que, ao ganharem o logradouro acima mencionado, os guardas avistaram KAUAN, que estava em frente da residência de número 70, e viram quando ele entregou 1 porção de droga para outro indivíduo, posteriormente identificado como Wilian Samuel do Amaral. Ao perceber a aproximação da viatura, KAUAN correu para o interior do imóvel, sendo de pronto perseguido pelos Guardas Cíveis, que lograram alcançá-lo e efetuaram a detenção, momento em que ele estava dispensando drogas dentro do vaso sanitário. Em revista pessoal, os guardas encontraram 4 porções de cocaína e 17 porções de "maconha", individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R\$ 689,00 em espécie, dinheiro angariado com a venda de drogas que ele promovia naquele local. Na residência, os guardas ainda encontraram 1 vaso contendo uma muda de "maconha" pertencente ao acusado, planta que se constitui em matéria-prima para a preparação de drogas. Com Wilian, os Guardas encontraram 1 porção de cocaína que ele havia acabado de comprar de KAUAN, a quem o acusado vendeu pelo preço de R\$ 30,00. Notificado pessoalmente (fls. 87), o réu apresentou Defesa Preliminar (fls. 94/101). Então, procedeu-se o regular recebimento da denúncia em 07 de abril de 2022 (fls. 105/110). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas e, ao final, interrogado o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia. De outro giro, a Defesa Técnica pugnou pela absolvição do réu, sustentando, em apertada síntese, insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para porte de drogas para uso próprio, bem como, em caso de condenação pelo crime narrado na exordial, pela concessão de todos os benefícios legais cabíveis a incidir na dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 19/20, bem como certidões a fls. 21/22. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Preliminarmente, indefiro o pedido da Defesa do acusado de instauração do incidente de dependência toxicológica pelas razões a seguir articuladas. Ora, é necessário frisar que a submissão do agente processado criminalmente ao incidente de dependência toxicológica é critério do julgador e não direito do acusado (TJSP- Rel. Dante Busana - RJTJSP 118/563).

Portanto, ainda que a pessoa se declare viciada ou dependente, tal afirmação não obriga, por si só, à realização do incidente, que somente deverá ocorrer quando houver dúvida sobre eventual dependência, nos moldes do artigo 149, "caput" do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente aos crimes de entorpecente. A dúvida somente surgirá se no curso do processo existirem elementos capazes de indicá-la, no que diz respeito à integridade mental do acusado ou quando sua conduta delituosa ocorreu em razão da dependência toxicológica. Raciocínio diverso obrigaria o julgador aos termos da manifestação unilateral do acusado, que certamente resultaria no atraso do término do processo, dada as sabidas dificuldades na conclusão do incidente em tempo razoável, ensejando indevidamente excesso de prazo na custódia cautelar do acusado. Deste modo, não será a simples afirmação do acusado no sentido de ser usuário ou dependente à droga que implicará em dever incondicional do juiz, a quem cabe zelar pela regularidade e andamento do processo, em determinar a realização do citado exame, devendo-se atentar ao comportamento do acusado, aos indícios e circunstâncias dos autos para que se possa superficialmente detectar a mínima anomalia psicossomática do réu, capaz de justificar a instauração do incidente, consoante iterativo entendimento Pretoriano: "A simples declaração do réu de ser dependente de drogas não obriga o juiz do processo a determinar a realização do exame toxicológico, cabendo ao julgador aferir a real necessidade de sua realização para a formação de sua convicção em cada caso concreto, dentro de sua discricionariedade regrada. Precedentes do S.TJ e do C. S.T.F. Nulidade para cujo reconhecimento faz-se necessário percuente reexame do conjunto probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. Ordem denegada" (HC 16.327/SP – Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca – DJU 02.09.2002, p 211). E mais, outra circunstância relevante está associada ao disposto nos artigos 45 e 46 da Lei 11.343/06, segundo o qual a isenção de pena ou sua redução em função de eventual incapacidade plena ou parcial gize-se ao tempo do delito do delito, para determinar-se de acordo com esse entendimento. Na lição do Ilustre Jurista Roberto Lyra, ao discorrer sobre os requisitos da inimputabilidade, do sistema biopsicológico adotado tanto pela Parte Geral do Código Penal de 1.940 e do Atual (Lei 7.209/84), bem como pela Lei 11.343/06, leciona que expressão, ao tempo da ação equivale ao pressuposto cronológico, que juntamente com o requisito causal e consequencial formam o quadro da inimputabilidade do agente. Ora, o citado requisito cronológico somente estará presente, justificando assim a instauração do incidente, quando forem azealhadas aos autos provas concretas de que o acusado estava sob o efeito do uso de entorpecente no dia do delito do qual está sendo acusado, vale dizer, se a eventual dependência decorrente do uso crônico e prolongado da droga, tal como ocorre com a doença mental, lhe tivesse retirado a capacidade intelectual e de autodeterminação no momento da prática do fato considerado delituoso, o que inooreu no caso em apreço, nada tendo os policiais relatado neste sentido. Em síntese, como bem salientado pelo Ilustre Ministro Celso de Melo, no HC 70.268 na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a perícia somente será necessária quando presentes duas condições: a) quando houver dúvida a respeito do poder de autodeterminação do acusado, à vista de elementos existentes nos autos; e b) quando houver evidência que a conduta foi realizada em virtude de dependência do uso de substância entorpecente. In casu, nenhum dos requisitos acima elencados mostraram-se presentes, posto que, não obstante o acusado tenha se declarado usuário de maconha, não mencionou passagens por clínicas para tratamento de sua suposta dependência, bem como não

revelou, em seu interrogatório judicial, qualquer sinal ou indício capaz de confirmar tal alegação, vale dizer, expressou-se de forma lúcida e articulada ao apresentar sua versão acerca dos fatos, inexistindo, assim, qualquer indício de comprometimento mental resultante do eventual uso de entorpecentes que fosse apto a justificar a instauração do incidente em exame. Note-se que o réu pontuou fazer uso de maconha apenas a noite, fazendo crer, que não há prejuízo a quaisquer de suas atividades. Vencida a questão preliminar arguida, passo ao exame da matéria meritória. Pois bem, o pedido acusatório comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada à

tipicidade da conduta. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo auto de constatação preliminar (fls. 07), pelo laudo do exame químico-toxicológico (fls. 63/65) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. O réu, em sede policial (fls. 13), manteve-se silente. Em juízo confessa os fatos, disse que está arrependido. Foi pego na parte de dentro de sua casa, apenas seu irmão estava na parte de fora da residência. Tinha dado um banho na sua filha e estava com seiscentos reais de um aluguel e metade iria comprar coisas para sua filha. Estava vendendo há 03 meses, para manter sua casa - tem uma mulher e dois filhos. Tem 18 anos. Tem passagem na vara da infância e juventude por tráfico. Ficou 03 anos em Campinas e não se envolveu com o tráfico. Estava trabalhando com jardinagem. É seu primeiro processo depois dos 18 anos. É usuário de maconha e faz uso a noite. Nunca ficou internado. O pé de maconha era para seu consumo. De outro lado, o Guarda Civil Municipal Sergio Henrique Carriel, ouvido em sede policial (fls. 09), narrou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina com sua equipe, quando foram averiguar o teor de "denúncia anônima" sobre tráfico de drogas ocorrendo no Jardim Santa Rita de Cássia desta cidade de Tatuí, precisamente na rua João Abrame, 70. Segundo informações, 01 (uma) pessoa do sexo masculino fazia o comércio ilícito de drogas em frente à residência. Assim, diligenciaram e constataram a veracidade da notícia criminis, pois, ao chegarem ao local indicado, logo observaram quando uma pessoa do sexo masculino entregou uma porção de droga para outra, razão pela qual deliberaram pela imediata abordagem. Ocorre que esta pessoa que entregou a droga percebeu a presença estatal e fugiu para o interior da residência, sendo devidamente acompanhado e detido enquanto descartava substâncias no vaso sanitário. Pelo que percebeu, o agente descarta drogas. Afirmou que, com esse sujeito, foram encontradas 04 (quatro) porções de cocaína, 17 (dezesete) de maconha e um arbusto desta planta, além da quantia de R\$ 689,00 (seiscentos e oitenta e nove reais). Por fim, o agente foi identificado como KAUAN GABRIEL DIAS MARCELO. O segundo agente, ou seja, aquele que adquiriu a droga, foi identificado como Wilian Samuel do Amaral, sendo encontrado em sua posse 01 (um) papelote de cocaína, no caso, aquele que acabara de adquirir de KAUAN. Em juízo disse que estavam em patrulhamento pelo bairro quando foram abordados pelo motoqueiro na rua João Abrame, que apontou o comércio de drogas no endereço correspondente a casa do réu. Foram ao local, viram o réu entregar algo para um indivíduo e o réu ao avistar a viatura correu para o interior da residência. Revisto o indivíduo que estava do lado de fora e com ele foi encontrada uma porção de cocaína do tipo Aricanduva. Wilian confessou que comprou a porção de Kauan e Kauan por sua vez admitiu o comércio e foi abordado pelo GCM Geraldo. Já conhecia o acusado desde a menoridade. Convergindo em mesmo sentido, o Guarda Civil Municipal Geraldo Coelho, em depoimento policial (fls. 10), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, disse que estavam em patrulhamento pelo bairro quando um indivíduo que conduzia uma moto e não quis se identificar disse que no endereço dos fatos ocorria a venda de entorpecentes. Ao virem nessa rua viram Kauan entregar algo para Wilian. Ao se aproximarem Kauan correu para o banheiro para dispensar o entorpecente. Localizaram uma porção com Wilian, com Kauan, não sabem dizer se ele conseguiu dispensar algo no vaso sanitário ou não. Já tinha abordado Kauan no bairro mas nas outras abordagens não tinha informação que ele estivesse traficando. Indagado sobre as apreensões de Kauan quando menor, a testemunha disse não se recordar. Perguntas da defesa - a droga estava junto com o réu Kauan. A maconha estava na caixa o relógio de força e a cocaína estava em poder do réu e foi encontrado durante a revista. O réu assumiu a mercancia e não estava sob efeito de substância entorpecente. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e

valor probatório. Nesse sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Finalmente, a testemunha Wilian Samuel do Amaral, em solo policial (fls. 11), afirmou ser usuário de drogas e, na data dos fatos, foi até o Bairro Santa Rita para comprar cocaína. Assim, sabedor de uma pessoa que venderia em sua residência fez a aquisição de tal droga, sendo acertado o preço de R\$ 30,00 (trinta reais) por um papelote. Após fazer o pagamento e receber a droga, ele (depoente) e o vendedor perceberam a presença de guardas civis municipais, os quais testemunharam a compra. Com isso, o vendedor correu para dentro da residência e ele foi abordado na rua, sendo encontrada a porção de cocaína adquirida. Em juízo, disse que é usuário de cocaína e que no dia dos fatos iria comprar uma porção de cocaína de Kauan pelo valor de trinta reais. Tinha visto o réu na frente do portão e perguntou se ele tinha uma porção para lhe vender, ele disse que tinha, lhe entregou e logo foram abordados. Tem 26 aos e consome cocaína desde os 11. Não tinha comprado de Kauan anteriormente. Ouviu comentários na vila que ele vendia. Os policiais os levaram para delegacia. Foram revistados no quintal. Quando os policiais chegaram estava no portão e os policiais o colocaram no quintal. O portão estava encostado, os policiais abriram e pegaram Kauan no quintal. Não sabe onde os policiais encontraram a droga, pois ficou no quintal. Examinando o arcabouço probatório emergente dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os insuspeitos e coerentes depoimentos dos agentes de segurança, os quais relataram, em uníssono, terem apreendido parte dos entorpecentes com o acusado e o restante na residência dele; e 2) o laudo do exame químico-toxicológico (fls. 63/65), cujo teor atesta que as substâncias apreendidas eram entorpecentes. Assim, indisfarçável é a finalidade mercantil das drogas, a despeito do acusado não ter sido flagrado vendendo drogas. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) a localização do réu em ponto de tráfico de drogas, oportunidade em que apresentou comportamento suspeito, pois, ao ver a viatura, ingressou rapidamente em sua casa e tentou se desfazer os entorpecentes que estava consigo; 3) a não localização de instrumentos ou apetrechos para o uso de drogas; 4) a forma de acondicionamento da droga, em pequenas porções, forma típica da "venda a varejo" de entorpecentes; 5) o depoimento da testemunha Wilian, de que comprou drogas do acusado e 6) a confissão

do réu. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Dês. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o

local onde os apelantes se encontravam era “ponto de tráfico” e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de “cocaína” em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo “ependrof” de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654; RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exames químico-toxicológico a fls. 63/65) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33 da Lei 11343/06 – trazer consigo e guardar –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o fato típico narrado na exordial, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2.006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. Fixo, portanto, sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, observo que, a despeito do acusado possuir menos de 21 anos quando dos fatos, bem como ser confesso, deixei de aplicar a respectivas atenuantes, já que a pena-base fora fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ). Mantenho, pois, inalterada sua pena. Convém destacar a inaplicabilidade da incidência da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: “Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o

cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Em terceira fase, presentes os requisitos legais do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/2, patamar aquém do máximo legal em virtude do histórico infracional do réu enquanto adolescente (fls. 22). Nessa esteira, fixa sua pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a qual torno definitiva, ante a minguagem de outras causas modificadoras da pena a incidir. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fundamento nos artigos 33 e ss., c/c o artigo 59, inciso III, todos do Código Penal, determino que o réu inicie o cumprimento da pena no regime semiaberto, considerando o histórico infracional do réu enquanto adolescente (fls. 22). Essas mesmas razões, obstam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A quantidade de pena inviabiliza a aplicação do sursis. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu KAUAN GABRIEL DIAS MARCELO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade, considerando que as razões que determinaram a prisão preventiva do acusado ainda permanecem presentes. E mais, trata-se de réu que desde a adolescência se dedica a atividades ilícitas (fls. 22), havendo risco de que, solto, torne a delinquir. Revela-se, pois, a imprescindibilidade da manutenção de sua prisão preventiva para garantir a ordem pública. Providencie-se a remoção do réu à estabelecimento prisional compatível com o regime de sua pena. Oficie-se para que o acusado seja imediatamente colocado em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto aplicado a ele nesse ensejo. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intimem-se o réu para que efetuem o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que os entorpecentes apreendidos já foram periciados, destruam-se as drogas na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art.91, II, "b", do Código Penal, c.c. art.63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do bem apreendido (R\$ 689,00 em dinheiro - fls. 05), pois comprovada sua proveniência criminosa, em favor da união, apropriados ao Funad (§1º do referido art.63). Pelo Defensor do acusado e pelo representante do Ministério Público foi dito que manifestariam eventual interesse recursal dentro do prazo legal. A seguir pela MMª Juíza foi dito: "Aguarde-se o decurso do prazo para a interposição de recursos pelas partes e, após, tornem os autos à conclusão". Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo

digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA